

1502344-89.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

...

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502344-89.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502344-89.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JANECÍ FERREIRA DE MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi

Vistos.

JANECI FERREIRA DE MORAIS, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 09 de Setembro de 2021, por volta das 11h40min, na rua Yaeno Hayshida, na via pública, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, o réu teria adquirido e guardado, 25 (vinte e cinco) porções de "crack" (produto derivado da cocaína) e 14 (quatorze) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para comercialização e entrega a terceiro, além da quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas (auto de exibição e apreensão - fls.09/10; laudo de constatação - fls.13/15).

Conforme a denúncia (fls.64/65) e, segundo o apurado, o réu, hipoteticamente, resolveu realizar comércio ilícito de drogas e, para isso, guardava as substâncias acima mencionadas, individualmente embaladas, no interior de uma bolsa, para venda a terceiros. Na ocasião, Policiais Civis, em tese, receberam informações sobre a prática do tráfico de drogas no endereço referido, sendo-lhes fornecidas as características das vestimentas do sujeito responsável pelo comércio ilícito, bermuda cor preta e camiseta regata cor azul clara. Com as informações, os policiais diligenciaram até o local e avistaram o réu com o mesmo tipo de roupas descritas conversando com outro indivíduo em uma motocicleta, o qual lhe entregou algo. Na sequência, o réu, teoricamente, foi até uma área próxima, abandonada, de

onde desenterrou uma bolsa de mão. Diante da atitude suspeita, os policiais resolveram abordar o réu, porém o outro indivíduo da motocicleta conseguiu empreender fuga. Realizada busca pessoal, teria sido encontrada a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, e a bolsa acima referida, que continha 25 (vinte e cinco) porções de "crack" (produto derivado da cocaína) e 14 (quatorze) porções de cocaína, e mais R\$ 50,00 (cinquenta reais). Assevera, a denúncia, que o denunciado foi flagrado com substâncias ilícitas, especialmente embaladas, de diferentes qualidades e diversas quantidades, divididas de forma a permitir a imediata comercialização, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de drogas.

O réu foi preso em flagrante às fls.01.

Termo de Audiência de Custódia às fls.25/29, oportunidade em que convertida a prisão em flagrante em preventiva, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais, com base nos artigos 282, § 6º, e artigos 310, inciso II e 312, todos do Código de Processo Penal. Mandado de Prisão fls.30/31.

A Defensoria Pública impetrou ordem de Habeas Corpus com pedido liminar, de acordo com fls.35/41. Sobreveio despacho às fls.42/43 em que indeferiu a medida liminar.

Às fls.45/47, prestadas as informações requisitadas junto ao Habeas Corpus.

Regularmente notificado (fls.84), o réu, por intermédio de advogado dativo, apresentou defesa prévia às fls.91/95, pugnando que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares, a fim de que responda o processo em liberdade e que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao acusado, com base nos artigos 4º e §1º da Lei nº 1.060/50, com a redação introduzida pela Lei nº 7.510/86. Ao final, o réu arrolou as mesmas testemunhas do órgão acusador.

Decisão às fls.97/98 recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento e indeferiu o requerimento de revogação da prisão provisória.

A d. defesa impetrou ordem de Habeas Corpus repressivo com pedido de tutela antecipada às fls.101/106. Despacho às fls.107/108 em que indeferida a liminar.

Em audiência de instrução e julgamento (fls.143/144), foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, interrogado o réu e mantido o decreto prisional.

Em alegações finais, o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ante a natureza nociva das drogas apreendidas, quais sejam, cocaína e crack; na segunda fase, presente a agravante do crime ter sido cometido durante estado de calamidade pública, diante da pandemia da Covid-19, compensando a mesma com a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, não estão presentes causas de aumento ou diminuição, afastando o privilégio do artigo 33, §4º, da LD, pois o réu relatou que trabalha para uma organização maior e estava labutando para pagar sua dívida decorrente do tráfico, revelando seu envolvimento direto com tal organização. No que tange ao regime, requereu o inicial fechado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena, negando, por fim, o benefício de recorrer em liberdade.

A d. defesa, por sua vez, pugnou pela parcial procedência da ação penal. Observou, quanto à dosimetria da pena, que na primeira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal; na segunda fase, indicou que a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", não merece prosperar, estando presente, ainda, a atenuante da confissão; na terceira fase, destacou que é caso de aplicação do artigo 33, §4º, da LD, no patamar máximo. No que toca ao regime, requereu o inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o benefício do réu recorrer em liberdade e, por fim, a aplicação da detração.

Certidão de Antecedentes Criminais às fls.22 e Folha de Antecedentes às fls.129/131.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01), Termo de Depoimento (fls. 02 e 03), Interrogatório (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls.09/10), Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (cocaína - massa líquida: 3,4g e 9g - fls. 13/15), Nota de Culpa (fls.16), Laudo de Lesão Corporal Cautelar (fls.23/24), Depósito Judicial (fls.57), Relatório Final (fls.59/60), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (cocaína - fls.80/82 e 140/142), Laudo de Constatação e Descrição de Objetos (fls.85/87), bem como pelas provas orais colhidas. Logo, é certo que restou devidamente comprovado o objeto material "droga", indicado no tipo penal do caso vertente, que prevê crime não transeunte, sendo regularmente apreciados os seus vestígios em prova tarifada pelo legislador (artigo 158, do Código de Processo Penal c.c. artigo 50, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/06 - LD).

Sobreleva notar que tal substância encontra-se expressamente prevista na Portaria 344/98 e Resolução nº 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (artigo 1º, Sú., da LD).

De outra banda, verifico que a autoria restou delineada, ante a consonância dos elementos colhidos na fase inquisitorial com aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastasse, o réu, em seu interrogatório, confessou a prática do delito, e explanou que, estava morando nas ruas; é usuário; estava sendo ameaçado, pois havia "rateado umas drogas dos cara" (sic); lhe disseram que iriam matá-lo, caso não fosse vender a droga; não iria ter lucro, pois trabalharia para pagar sua dívida; devia R\$ 2.000,00 (dois mil reais); rateou diversas porções de droga, mas era para uso; tratava-se de maconha, crack e cocaína; é usuário de cocaína; quanto às outras substâncias, faria uso com amigos; havia começado a traficar no dia anterior aos fatos; não tem conhecimento de quanto tempo teria que trabalhar até pagar sua dívida; a droga apreendida era para a venda; o dinheiro que estava em sua posse era fruto da mercancia; não conhece, realmente, os traficantes que vendiam drogas para si; comprava drogas com os mesmos algumas vezes; não fazia parte da organização criminoso.

A par disso, a testemunha Flávio Fernandes Fagundes, Policial Civil, em juízo, narrou que, receberam uma ligação anônima dizendo que uma pessoa estava praticando o tráfico no local dos fatos; descreveram como o réu estava trajado e o que estava ocorrendo; foram com uma viatura descaracterizada e observaram por certo tempo; visualizaram uma motocicleta parar, momento em que o réu foi até o motociclista que passou algo para ele, saindo posteriormente e indo para um terreno baldio; abordaram o réu no terreno baldio; havia R\$ 50,00 (cinquenta reais) com o réu e o mesmo estava desenterrando uma bolsa do terreno; dentro da bolsa havia mais R\$ 50,00 (cinquenta reais), cocaína e crack; o réu logo admitiu que estava traficando; o motociclista se evadiu; não conhecia o réu de outras abordagens; a quantidade de papéletes de cocaína era menor do que a quantidade de papéletes que continham crack; o réu não referiu de quem era as substâncias entorpecentes.

Igualmente, a testemunha João Justino de Oliveira Sobrinho, Policial Civil, declarou que, o local é conhecido como ponto de tráfico; no dia dos fatos, receberam uma ligação, informando que teria uma pessoa de cor parda, trajando bermuda e camiseta regata de cor azul, vendendo entorpecentes; se dirigiram até o local em viatura descaracterizada; em 30 minutos observaram a movimentação e concluíram que o denunciado estava traficando; um rapaz que dirigia uma motocicleta conversou com o réu; o réu entrou em um terreno; seguiram o denunciado e notaram que ele desenterrou uma bolsa, e então o abordaram; dentro da bolsa havia R\$ 50,00 (cinquenta reais) e mais R\$ 50,00 (cinquenta reais) com o réu; havia 10 papéletes com cocaína e 25 papéletes com crack; o denunciado confessou o delito, disse que era morador de rua e para manter o vício teria que praticar a venda; conduziram o réu até a delegacia, momento que feito o flagrante; acredita que abordou o réu na semana anterior aos fatos, mas não foi encontrado entorpecentes com ele.

Ressalta-se que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTVOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Como se vê, a prova é robusta o suficiente para embasar uma condenação, pois hialino que o réu praticou os núcleos "adquirir", "guardar" e "vender", previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tipo misto alternativo, sendo certo que houve a apreensão de quantidade de droga suficiente para lesionar o bem jurídico tutelado, e já devidamente fracionada para venda, ainda mais porque não comprovou que exercia qualquer atividade remunerada à época dos fatos, donde se vê que sua conduta causou grande dano à saúde pública, além do fortalecimento de organizações paraestatais, violando o bem jurídico tutelado pela norma penal. Outrossim, extrai-se o seu intuito comercial do próprio local em que concretizada a abordagem, qual seja, ponto de mercancia de drogas.

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT776/663). Logo, ainda nesta hipótese, restaria consumado o crime.

Por fim, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e é adotado pelo Código Penal no artigo 68, passo à dosimetria da pena, anotando, desde já, a primariedade do agente.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atenta aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal e ao disposto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que diante da natureza distinta entre os entorpecentes e potencial lesivo, a pena deve ser exasperada em 1/8. Destarte, fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa.

De outro lado, incide a atenuante da confissão, utilizada para a formação do convencimento desta magistrada, imperiosa a incidência do disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Assim, reduzo a pena para o patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

No mais, não há falar na aplicação da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, no que concerne a pandemia da Covid-19, porque, como decide o E. TJSP, "faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19. Assim, não havendo nexos causal entre a situação de pandemia e a conduta do agente, de rigor o afastamento da agravante em questão, mantendo-se inalterada a reprimenda." (TJSP, Apelação Criminal nº1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. ANDRADE SAMPAIO, 1ª Câmara de Direito Criminal, j.12.02.2021). Ainda, o E. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito" (HC nº 654255/SP, 6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 25.05.2021, DJe 07.06.2021).

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e possível a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da LD, dado que o réu é primário, de bons antecedentes e não restou cabalmente demonstrado que se dedicava às atividades

criminosas, tampouco que integrava organização criminosa. Assim, diminuo a pena em 1/2, tornando a pena definitiva em 2 anos e/ 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. Assim, "Tratando-se de réu primário e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção do paciente em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe." (STJ, AgRg no HC 705.950/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

O regime inicial será o aberto, em exegese ao artigo 33, do Código Penal. Possível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, por ser medida mais adequada para absorção da terapêutica penal. Justifica-se a substituição por duas restritivas de direitos em razão do lapso temporal da pena substituída.

Cabível a substituição da pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal, não há que se falar em suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

Ante o exposto, e por tudo o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JANEI FERREIRA DE MORAIS à pena de 2 anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, "caput", e parágrafos, do Código Penal), por restar incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo a prestação de serviços à comunidade pelo tempo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, diante da fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito. Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu estiver preso.

Ainda, atendendo a nova redação do artigo 387, § 2º, Código Processual Penal, dada pela Lei 12.736/12, deixo de proceder à detração da pena, ante a inconstitucionalidade do dispositivo, por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

Como a quantia apreendida e o bem apreendido estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva - fruto da mercancia da droga-, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (artigo 72, da LD).

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.
Expeça-se guia de execução penal.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
P.I.C., Mairiporã, 30 de Março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA